

1500284-08.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, temos: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500284-08.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500284-08.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos-Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199593/2021 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 19213674 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 177/21/508 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 2199593 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARCELINO APARECIDO ABRUCESE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

GABRIEL MARCELINO APARECIDO ABRUCESE foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, supostamente, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 16h47min, na Rua Doutro Lauro Ferreira Braga, nº 911, nesta cidade e Comarca, o réu tinha em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, 06 (seis) porções de cocaína, com massa líquida de 1,76 gramas. A Decisão de fls. 143/144 recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. Devidamente citado (fl. 155), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 149/152. Em audiência de instrução e julgamento realizada em 26 de outubro de 2021 foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da acusação e 02 (duas) testemunhas de defesa, além do interrogatório do réu. Na oportunidade, o Ministério Público apresentou as suas alegações finais oralmente, requerendo a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, sendo que a materialidade e autoria é certa. Das provas, revelam-se suficientes para a condenação as 06 (seis) porções de cocaína encontradas em cima da geladeira do réu, além de diversos plásticos para embalar entorpecentes e uma

quantia em dinheiro que o réu não soube explicar satisfatoriamente a sua origem. Ademais, informalmente aos policiais o réu confirmou que estava realizando o tráfico para auxiliar em sua condição financeira. Na fixação da pena, esta pode ser dosada no mínimo legal, vez que o réu não possui antecedentes criminais. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem apreciadas. Na última fase, não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, visto que há meses, como noticia os policiais, se tem notícias de que o réu pratica o tráfico de entorpecentes naquela região.

De seu turno, a defesa apresentou memoriais escritos às fls. 276/283. Em suma, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, vez que não está cabalmente demonstrado a prática de tráfico de entorpecentes, sendo que a droga apreendida no momento do flagrante era para seu uso pessoal e não disseminação. Subsidiariamente, e, caso de condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu, porque, supostamente, no dia 23 de julho de 2021 o réu cometera o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante de fl. 03, dos termos de depoimentos de fls. 04/06, no boletim de ocorrência nº 177/2021 juntado às fls. 09/11, do auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, nas fotografias de fls. 25/37, do laudo 244.864/2021 (fls. 133/135) que detectou a presença da substância de cocaína e do laudo 171.244/2022 de fls. 256/260 acerca do aparelho telefônico apreendido.

Ademais, a autoria é certa e recai sob o réu, conforme demonstra as provas delineadas nos autos.

Dando ênfase nos elementos informativos colhidos em solo policial, em juízo foi colhida a seguinte prova oral:

A testemunha RODRIGO CINTRA NUNES, policial militar, quando inquirido em juízo, relatou que: estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia via Copon de que o réu estaria embalando drogas para comércio e que havia uma moto vermelha na sua residência para buscar parte dos entorpecentes. Chegando no local, estava somente o réu, foi feita a abordagem no acusado, onde nada foi encontrado em busca pessoal. Informalmente disse aos policiais que estava vendendo drogas e deu autorização para que os milicianos adentrassem à sua residência. Que em cima da geladeira achou 06 (seis) porções de cocaína já embaladas e prontas para comércio. Que perto do local também foi encontrado bastante plástico para embalar os entorpecentes, além de alguns remédios, que comumente são utilizados para fazer a mistura juntamente com a cocaína. No mais, foi achado R\$ 356 (trezentos e cinquenta e seis reais), onde o réu não soube explicar a procedência do dinheiro. Aos policiais o réu disse que estava traficando para levantar um dinheiro para o conserto de seu carro. Que as denúncias se estenderam por mais de 01 (um) ano, e que já abordou o réu juntamente com outras pessoas que também estão envolvidas com o tráfico de entorpecentes na área. Que o réu desbloqueou o celular e deu autorização para que os policiais olhassem o seu conteúdo, onde foi possível verificar vários anúncios de venda de entorpecentes.

A testemunha LUIZ ROGÉRIO PINTO, policial militar, quando de seu depoimento em juízo, sobre os fatos relatou que: estava em patrulhamento e que por via Copom recebeu uma denúncia de que o réu estaria embalando drogas para comércio e que uma moto vermelha estaria estacionada para buscar os entorpecentes. Chegando no local a referida moto já não estava no local, sendo que prosseguiram com a abordagem no réu, que estava saindo de casa no momento. Foi encontrado uma quantia em dinheiro com o acusado e indagado sobre a existência de drogas na residência, a princípio negou, tanto que autorizou os policiais a adentrarem na residência e acompanhou a vistoria feita pelos policiais. Na vistoria, o parceiro da testemunha encontrou em

cima da geladeira 06 (seis) porções de cocaína embaladas para comércio. Apresentado o entorpecente encontrado para o réu, ele prontamente assumiu que era sua e relatou que estava vendendo pequenas porções de drogas para juntar dinheiro para consertar o seu carro. Sobre as denúncias recebidas referente ao réu, essas eram frequentes, tendo perdurado por meses. Que em nenhum momento o réu alegou que as drogas eram para uso, sendo dito aos milicianos que o entorpecente era para venda. Que os plásticos picados eram idênticos aos pedaços encontrados na droga embalada. Que viu as mensagens de negociação de entorpecentes, onde o próprio réu teria mostrado tais mensagens. Sobre o dinheiro encontrado, primeiramente o réu disse que lhe pertencia, mas que indagado pelos policiais no momento em que disse que estava desempregado, o réu disse que estava juntando para pagar o documento do carro, porém não se recorda se o réu disse que o dinheiro era proveniente do tráfico. A testemunha de defesa MARCELO ALVES DA CRUZ, quando de seu depoimento em juízo, relatou que: é vizinho do réu por aproximadamente 01 (um) ano e que não presenciou os fatos ocorridos. Que nunca viu movimento de tráfico na casa do réu. Que já viu o réu fumando maconha na frente de casa, mas que nunca observou alguma movimentação de usuários no local.

A testemunha de defesa LUIZ CARLOS CALIXTO PEREIRA, inquirida em juízo, disse que: é vizinho do réu e que não presenciou a sua prisão. Que o réu trabalhava com um transporte de mudança e depois trabalhava de entregador com uma moto. Que nunca viu movimentação de tráfico na residência. Que não tem certeza se o réu utiliza drogas, mas acredita que sim, pois o cheiro que vem da casa é muito forte.

O réu, quando de seu interrogatório em juízo, disse que: faz uso de maconha e cocaína há 02 (dois) anos e alguns medicamentos, visto que por conta da pressão alta tem bastante dor de cabeça. Sobre os fatos, narra que não autorizou os policiais a mexerem em seu celular e que o celular não estava com senha, sendo que o celular estava do lado de sua carteira e colocaram em cima do carro, e que estava acompanhando a vistoria em sua residência com um policial e ou outro ficou com seu celular e sua carteira e já foi abrindo o celular sem a sua autorização, dizendo que tinha várias coisas de tráfico ali. Que as drogas eram para consumo pessoal; que conhecia os policiais por ser usuário, e que realizaram uma outra abordagem; que não tem nenhum desentendimento com os policiais; que com o policial Rodrigo teve um desentendimento na primeira abordagem, e com Luiz Rogério não teve nada. Que o dinheiro estava juntando para pagar o documento do carro, oriundo do seu serviço de mototáxi e com o serviço de motorista.

Pois bem.

Como se observa das provas colhida dos autos, o réu não admitiu expressamente a prática do delito de tráfico de drogas, apresentando uma versão exculpatória de que os entorpecentes eram para o seu uso e não para disseminação. Ocorre que tal versão não condiz com elementos probatórios trazidos nos autos.

Os policiais militares enfatizaram, tanto em solo policial e em juízo, que o réu estava em situação de traficância, situação que, segundo os milicianos, fora confessada pelo réu informalmente no momento de sua prisão. Anote-se que a suposta confissão informada aos militares não poderá ser validada por este juízo, uma vez que no crivo do contraditório o réu apresentou versão totalmente diversa, que deverá prevalecer sob os elementos de convicção do julgador. Porém, tal versão do réu, novamente, não se amolda para uma eventual absolvição ou desclassificação do crime.

Isso porque nos autos há elementos suficientes que demonstram que o réu estava realmente praticando o tráfico. O laudo de fls. 256/260 referente ao aparelho celular apreendido, demonstra que "As conversas encontradas no aplicativo "WhatsApp" com os contatos "Bebe Barra - +55 18 99692-5610"; "Negão Rogério - +55 18 99717-6697"; "Royiii - +55 18 99797-6389"; "+55 18 99825-3276"; "Pastel - +55 18 99735-8470"; entre diversas outras abordam sobre a mercancia de entorpecentes. A conversa encontradas no aplicativo Facebook Messenger com o contato "Leandro Henrique" aparenta se tratar de negociação de munições de calibre .32" e .38" e com o contato "Guilherme Henrique" tratam de negociação de substâncias entorpecentes. Foram encontrados arquivos de mídia que retratam paisagem e fracionamento de substâncias entorpecentes na galeria do aparelho celular. (fl. 258).

Assim, alinhado com as demais provas juntadas, têm-se que a mercancia dos entorpecentes é clara, não se desincumbindo a defesa prova ao contrário. Fazendo uma análise do conjunto fático, resta que os indícios são claros do delito de tráfico de drogas. Nesse sentido, é lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No mais, em nada há que se ressaltar os depoimentos dos policiais, de modo que o fato de uma testemunha ser policial, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, mormente quando acompanhada de outros elementos hábeis a ensejar o decreto de condenação, o que é o caso dos autos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). Com efeito: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (HC nº 74.608-SP – STF).

E ainda: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal”.

“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 73.518 – SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Ainda, sobre o teor dos depoimentos dos milicianos, tanto em solo policial e em juízo, ressalto que não existe dispositivo legal que vede aos agentes policiais servirem como testemunhas. Não se pode crer que os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente, de modo que as suas declarações, como demonstrada, está em consonância com os demais elementos probatórios.

Assim, resta claro o crime de tráfico de entorpecentes, de modo que alinhar a conduta do réu a outra tipificação seria contraproducente. Conforme previsto no art. 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de “trazer consigo” entorpecente para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto, em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, temos: “O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

A propósito, ressalte-se que para a caracterização do crime de tráfico de drogas

não é necessário que tenha sido flagrado em ato de venda.
Nesse sentido:

“Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ., rel. Des. Marco Antônio, j. 25/10/2007).”

E ainda:

“O crime de tráfico não se consuma apenas com o fato do agente trazer consigo o entorpecente, pois o tipo penal traz diversas figuras típicas, dentre as quais o depósito da droga, o que fica caracterizado na hipótese de o réu ter enterrado na sua residência a substância em local cercado por grades e, portanto, de difícil acesso a estranhos, não restando demonstrada a alegação de que a droga não era sua, ou que não tinha conhecimento da mesma (TJRS, Ap. 699.232.609, 3º Câ., j. 30-9-1999, rel. Des. Saulo Brum Leal, RT 777/688).”

De mais a mais, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, o que não se duvida que seja, isso não descaracteriza o crime.
Nesse sentido:

“O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga (“Tóxicos Prevenção Repressão”, Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p. 119).”

Ora, ainda que seja o acusado dependente químico, a circunstância não descaracteriza o crime.

Não é outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

Em suma, por tudo que se disse acima, não há que se falar em desclassificação do crime imputado na inicial acusatória (artigo 33, da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), sendo que a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes é a medida que se impõe. Mais, creio, não é necessário acrescentar.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa, observo que o réu não ostenta antecedentes criminais, motivo pelo qual, à míngua de circunstâncias judiciais negativas (fls. 41/44), fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, verifico que não incidem circunstâncias agravantes e tampouco atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última etapa, observo que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse ponto, faz-se necessário destacar que, segundo o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, processos em andamento e investigações, tal como eventuais denúncias anônimas sobre traficância, bem como a informação genérica e não comprovada, dada por testemunhas policiais, de que o réu é conhecido nos meios

policiais, apesar de não possuir antecedentes, não podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao princípio do devido processo legal (igualmente, processos em andamento e investigações não autorizam o aumento da pena-base). Por conseguinte, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), considerando o alto grau de nocividade da substância cocaína, vendida pelo réu, a quantidade considerável de drogas localizadas, 6 (seis) porções, o que denota o objetivo de comercialização, além dos petrechos para a disseminação do entorpecentes (20 embalagens), motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que não ficou demonstrado que o réu detém capacidade econômico-financeira para suportar exação maior.

Tendo em vista o quantum da pena aplicada, as circunstâncias concretas do fato, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional (artigo 77 do CP), em razão da pena fixada.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, não dependendo só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos, referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GABRIEL MARCELINO APARECIDO ABRUCESE, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual no piso legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e das despesas processuais, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que não surgiram causas para que a prisão se mostre imprescindível, mormente tendo em vista que o réu permaneceu solto durante boa parte da fase processual.

No que diz respeito aos entorpecentes apreendidos, como não houve impugnação aos laudos periciais e inexistem dúvidas quanto à natureza das drogas, OFICIE-SE à Autoridade Policial, independentemente do trânsito em julgado da presente sentença, comunicando a autorização para incineração, caso ainda não tenha ocorrido.

Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e ao IRGD comunicando a condenação, notifique-se a ré para o cumprimento da pena de multa, extraia-se guia de execução definitiva, providenciando a z.serventia o necessário para o cumprimento da pena.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos.

P. R. I.

Paraguacu Paulista, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA